

1503272-60.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Marlon foi novamente preso por tráfico.

O policial civil Filipe narrou que foi o responsável pela análise e confecção do relatório dos celulares apreendidos e encontrou dados atinentes à prática de tráfico. No telefone do réu havia uma conversa em que o interlocutor diz a Marlon que quer um "bagulho" e o acusado responde que não está na cidade. No celular da namorada do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503272-60.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233252/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19879296 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4796/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2233252 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON ADRIANO DA SILVA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

MARLON ADRIANO DA SILVA BORGES está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", cumulado com o artigo 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 209), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 282/288).

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 293) e o acusado foi citado (fls. 357).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 393/394).

Em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa arguiu nulidades e pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação da pena mínima legalmente cominada e das benesses legais.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/15), boletim de ocorrência (fls. 16/20), informação de fls. 22/30, auto de exibição e apreensão (fls. 31/33), fotografias (fls. 46/52), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 123/136), laudos periciais (fls. 137/143 e 213/217) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, Marlon negou a prática do delito e aduziu que somente a porção de 20g de haxixe lhe pertencia e era destinada ao seu próprio uso. Afirmou que não residia com sua genitora e o entorpecente foi encontrado no quarto dela. Foi abordado pelos policiais quando saía de sua residência para ir à casa de sua mãe, pois ela tinha telefonado assustada com o ingresso da polícia e o encontro do haxixe. No que atine aos eppendorfs vazios, afirmou que os tinha adquirido pela internet para um conhecido seu, e eles eram o “bagulho” mencionado por Gabriel na mensagem constante de seu celular. Não tinha conhecimento da existência das anotações extraídas do celular de sua companheira. Negou a propriedade do restante das drogas encontradas próximo à caixa d'água e disse que o local já era ponto de venda de entorpecentes antes mesmo de sua genitora mudar para o bairro. Aduziu que estava laborando com sua genitora na área de reciclagem e ganhava pouco porque trabalhava em troca de poder morar no imóvel do Bairro Cila Bauab. Não conhecia os policiais, contudo acredita que eles o perseguiram por terem desavenças com seu genitor.

L., companheira do réu, contou que estava com o acusado na residência situada no Bairro Cila Bauab quando foram abordados pelos policiais civis. No local nada foi localizado. As drogas foram encontradas próximo à residência da genitora de Marlon. Não sabia da existência das anotações em seu celular, tampouco tinha conhecimento do envolvimento de Marlon com o tráfico. É usuária de maconha, assim como o réu.

O policial civil Paulo relatou que participou do cumprimento de mandado de busca expedido em desfavor do réu. Estavam no imóvel a genitora e a avó dele e foi encontrada uma grande porção de haxixe no quarto de Marlon, além de centenas de eppendorfs vazios, de cores diversas, no meio de roupas que estavam no lado externo da casa. Sua mãe informou que ele tinha passado a noite em outra casa da família, situada no Bairro Cila Bauab, onde o encontrou em companhia da namorada deixando o local. Marlon alegou que o haxixe era para seu próprio uso. Retornaram à residência da genitora do acusado, vez que havia informações passadas por informantes e vizinhos de que Marlon exercia o tráfico em local próximo ao imóvel e armazenava os entorpecentes nas imediações de uma caixa d'água. Em diligências pelo local indicado, foram encontradas várias porções de cocaína – armazenadas em eppendorfs iguais aos que estavam na casa do réu – e maconha. Verificou uma mensagem no celular do réu em que terceiro pede a ele “um bagulho”. No telefone da namorada do acusado havia anotações de contabilidade do comércio espúrio. Após os fatos aqui tratados, Marlon foi novamente preso por tráfico.

O policial civil Filipe narrou que foi o responsável pela análise e confecção do relatório dos celulares apreendidos e encontrou dados atinentes à prática de tráfico. No telefone do réu havia uma conversa em que o interlocutor diz a Marlon que quer um “bagulho” e o acusado responde que não está na cidade. No celular da

namorada do réu havia anotações de pesos, valores e letras usualmente usadas para indicar o tipo de droga, indicativas de contabilidade de tráfico.

Pois bem.

Inicialmente, não se observa qualquer ilegalidade na expedição do mandado de busca e apreensão (autos nº 1503105-43.21021.8.26.0302), nos termos aventados pela defesa, pois a ordem foi determinada após decisão fundamentada que acatou as razões da autoridade policial, indicando o endereço conhecido de Marlon.

Tampouco há irregularidade na diligência policial concretizada no local indicado por sua genitora como aquele em que ele poderia ser encontrado. Nesse ponto, não há que se olvidar que os crimes em análise são de caráter permanente e Marlon já se encontrava em situação de flagrância com a apreensão do entorpecente de sua propriedade, fator que tornava, inclusive, a ordem judicial prescindível. A atuação policial para localizar e prender o acusado se apresenta como mera decorrência da diligência em andamento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – SUPOSTO CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRETEXTADO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA PARA MACULAR A DILIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 85.100 E 252.156] – PACIENTE DECLINADO COMO A PESSOA QUE EFETIVAMENTE SUPORTARIA OS EFEITOS DA DILIGÊNCIA – MATERIALIDADE 0,86G (OITENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 38,98G (TRINTA E OITO GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, A QUANTIA EM ESPÉCIE DE R\$ 3.320,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONTEXTO INDICATIVO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DELITO PERMANENTE –PACIENTE REINCENTE [EXECUTIVO DE PENA Nº 26519-10.2017.811.0042/SEEU] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Havendo, portanto, prova suficiente quanto a pessoa pormenorizada no mandado, não se tratando de uma diligência aleatória, mas sim de um procedimento, motivo pelo qual alegações calcadas no fato de que as supostas provas em desfavor do paciente foram colhidas ao arrepio do ordenamento jurídico, não encontram amparo, em especial porque afigura-se como equívoco material sendo fator que não desnatura a decisão que a deferiu. [...]”. (TJ-MT 10211512720208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2020).

Não se verifica a suscitada invalidade da prova obtida a partir das informações extraídas do aparelho celular pertencente ao réu e à adolescente. Os telefones do réu e da menor foram apreendidos por ocasião do cumprimento da diligência e a quebra de sigilo de dados estava amparada pela ordem judicial expedida contra Marlon e outros indivíduos.

Nessa seara, o voto do Excelentíssimo Desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho e acolhido por seus pares da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para denegar a ordem no Habeas Corpus 2236385-94.2021.8.26.0000 (fls. 198), impetrado em favor de Marlon: “... os autos não deixam dúvida de que naquele momento o paciente já se encontrava em flagrante delito, de natureza permanente, em virtude da apreensão do entorpecente encontrado em sua residência. Daí que além de ser legítima a atuação em flagrante, não existe nenhuma ilegalidade na apreensão dos aparelhos celulares, porquanto eles poderiam conter provas do envolvimento do agora paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, como de fato ocorreu ...”.

A autoria também restou comprovada.

Os policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido contra o acusado, localizaram uma porção de 20g de haxixe pertencente a Marlon e centenas de cápsulas plásticas usualmente utilizadas na embalagem individual de cocaína. Em continuação às diligências, guiados pelas informações no sentido de que Marlon mantinha drogas em depósito nas imediações de uma caixa d'água, os policiais encontraram várias porções de maconha e cocaína. Note-se que parte das porções de cocaína estavam embaladas em eppendorfs iguais àqueles armazenados em sua casa.

Some-se a isso a mensagem extraída do celular do acusado e as anotações financeiras encontradas no telefone de sua companheira, constantes da informação de fls. 22/30, que explicitam significativa movimentação financeira do tráfico.

De outro lado, os policiais civis foram firmes e coerentes em suas oitivas e, a despeito da alegação de Marlon, não foi comprovado qualquer motivo pelo qual desejassem incriminá-lo falsamente.

A finalidade de entrega a terceiro restou comprovada pela dinâmica da diligência policial, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da localização de faca com resquício de maconha (fls. 213/217), pelas anotações de tráfico e pela apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada, mormente diante da afirmação do réu em juízo de que praticamente não auferia renda monetária, e de sua companheira em sede policial de que não trabalha, apenas estuda (fls. 12).

Quanto à associação, embora o teor das anotações encontradas no celular da adolescente revele indícios desse delito, não são suficientes no caso concreto, por si só, para sua comprovação.

Nesse contexto, suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime de tráfico, de rigor a parcial procedência da ação penal.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, observo que a pena-base merece aumento em virtude da quantidade de entorpecentes armazenada pelo réu. Assim, fixo-a acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a pena no patamar acima fixado.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, vez que a infração foi cometida nas imediações de estabelecimento de ensino (fls. 28/29), e da majorante descrita no inciso VI do mesmo artigo, aumento a pena para 7 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o teor das anotações de fls. 25/26 comprovam que o réu se dedicava a essa atividade criminosa, inclusive com menção a grandes quantidades (quilos).

Considerando a pena aplicada e os motivos para afastamento da minorante e os esposados na primeira fase, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há,

portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, o réu MARLON ADRIANO DA SILVA BORGES à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, no mínimo legal, mas para ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA